

1502023-03.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Zilli, j. 17.05.2021); e

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleitos de afastamento do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da imposição do retiro pleno - Inviabilidade dos pedidos - Presentes os requisitos do "tráfico privilegiado", deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502023-03.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502023-03.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307075/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 15122302 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2222/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2307075 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES PICCINE LIRIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra MOISÉS PICCINE LIRIO (fls. 86/87), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso: Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 18h00min, na Rua Santana do Parnaíba, n.º 12, Jardim Ângela, Pirajussara, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, MOISÉS PICCINE LIRIO, qualificado às fls. 06, trazia consigo, tinha em depósito, vendia e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 70g (setenta gramas) de cocaína, acondicionada em 67 (sessenta e sete) microtubos de plástico, e 6g (seis gramas) de crack, acondicionada em 53 (cinquenta e três) invólucros de

plástico e papel alumínio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de constatação de fls. 32/34.

A denúncia foi recebida em 21.01.2021 (fls. 90/91).

Regularmente notificado, o denunciado apresentou defesa prévia, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 103/108).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 110/111).

Na data aprazada, colheram-se os depoimentos das testemunhas, e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (termo de audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), no boletim de ocorrência (fls. 16/18) e nos autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar das substâncias apreendidas (fls. 19/20 e 32/34) e no laudo definitivo (fls. 162/164). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidos em poder do acusado 70g (setenta gramas) de cocaína, acondicionada em 67 (sessenta e sete) microtubos de plástico, e 6g (seis gramas) de crack, acondicionado em 53 (cinquenta e três) invólucros de plástico e papel alumínio, além de R\$ 114,00 em espécie. O exame químico-toxicológico atestou que as substâncias entorpecentes apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa, exsurindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, os dois guardas civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, Thiago Dionizio Alves Costa e Victor Hugo Christão Muniz, apresentaram versões harmônicas, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Ambos relataram que: estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando receberam a informação de que um indivíduo de estatura mediana, compleição física "gorda", trajando bermuda jeans, camisa azul e boné vermelho, estava realizando a venda de substâncias pelo local dos fatos; deslocaram-se até ali, onde observaram o acusado, que apresentava as características repassadas, em cuja posse estava um pino de substância assemelhada à cocaína; a menos de um metro e a uma altura de 2 metros, localizaram o restante das drogas apreendidas, dentro de uma pochete, além de uma quantia de R\$ 114,00 em espécie; indagado informalmente, o implicado negou os fatos (fls. 4 e 5).

Em juízo, inquiridos como testemunhas, reproduziram, essencialmente, as narrativas extrajudiciais, atestando a veracidade dos fatos imputados na denúncia.

A informante do Juízo Nathalie Santana Ribeiro não presenciou os fatos, sendo meramente abonatória a sua versão.

Silente em solo policial (fl. 6), em juízo o réu negou os fatos imputados, alegando, em síntese, que a droga não lhe pertencia.

Como se vê, os seguros, claros e congruentes testemunhos dos guardas municipais, que têm eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - sobretudo em casos como o presente, envolvendo o tráfico de drogas, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu (como na espécie, até porque não o conheciam) -, formam quadro probatório suficiente à formação da autoria delitiva.

A defesa não comprovou o fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva alegado (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas da autoria.

Também não prospera o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o de posse de entorpecentes para uso próprio (art. 28 da mesma lei). A distinção entre as condutas criminosas em destaque é balizada, no caso concreto, pelos critérios estampados no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas. Conquanto a quantidade dos entorpecentes apreendidos não seja expressiva,

as condições em que se desenvolveu a ação - a droga estava fracionada e embalada, e em poder do agente foram encontrados R\$ 114,00 em espécie - assinalam com o comércio ilícito de drogas. É irrelevante se o acusado era usuário de drogas, já que, amiúde, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício (TJSP, Apelação Criminal nº 1500186-28.2018.8.26.0150, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.04.2021). E o direito penal esquadrinha fatos para identificar os seus autores (direito penal do fato), não partindo de perfis pessoais para daí discriminar as possíveis condutas criminosas em que estes incorreriam.

Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Noutra giro, é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado, benefício positivado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

O agente é tecnicamente primário, não ostenta maus antecedentes (fl. 28), e do apontamento infracional isolado (fl. 29) não é possível inferir que se dedique a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa, de maneira que faz jus ao reconhecimento da benesse em tela.

No tangente ao patamar de diminuição da pena, malgrado o § 4.º do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração redutora, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram a compreensão de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado - balizas do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 -, servirão para a escolha do quantum da redução.

Considerando que foi apreendida quantidade não portentosa de drogas e que não há nenhuma informação nos autos a desabonar a personalidade e a conduta social do réu, reputo adequado e proporcional a redução da pena no patamar máximo (2/3).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Recurso objetivando a aplicação do redutor no grau máximo e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório coeso. Confissão. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. Condições pessoais favoráveis que comportam a incidência do redutor no grau máximo, a fixação do regime aberto, que melhor se adequa às finalidades preventiva e retributiva da pena, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500290-

05.2020.8.26.0530, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 16.03.2021).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e não descortinadas causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a dosar as penas aplicáveis a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias discriminadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade e a variedade não exorbitantes de drogas não ensejam maior reprovação penal, e não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é inerente à espécie; o réu é primário; as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são próprios do tipo penal, não justificando maior reprimenda.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes, remanescendo a pena tal qual dosada na primeira fase.

Na terceira fase, concorre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual minoro a pena em 2/3 (dois terços) – na esteira do acima explanado –, e, à míngua de causas de aumento, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.700/MG, reafirmou o entendimento gizado de forma incidental pelo Plenário, no julgamento do HC 111.840/ES, de que é inconstitucional o art. 2º, § 1º, da lei 8.072/1990:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.

A dizer: a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo – compreensão que está em consonância com as Súmulas nºs 718 e 719 do STF.

Mais recentemente, sufragando a posição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do HC nº 596.603-SP, publicado em 22.09.2020, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Faustino Neto, condenado como incurso no art. 33, “caput” e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedeu ordem individual e coletiva, constando da parte dispositiva:

1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.

2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto.

3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face

de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.

4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

A Corte Superior de Justiça estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais de todo o País, dentre as quais:

2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD)

2.c. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução nº 5 do Senado Federal, decorrente do julgamento do HC 97.256, pelo STF).

Nessa ordem de ideias, fixo o regime aberto para início do resgate da penal corporal, porquanto inferior ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, e haja vista que o réu não é reincidente (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, sempre do Código Penal). Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos do art. 44 do Código Penal (pena concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; réu não reincidente em crime doloso; e suficiência e adequação da substituição da pena corporal, diante das circunstâncias judiciais, para atingir as finalidades da sanção), substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (§ 2º do mesmo artigo), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Em abono ao motivado, colho precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; b) fixação do regime inicial aberto; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Prequestionamento.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio.

2. Dosimetria da pena que merece reparo. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo. Atos infracionais que não constituem elemento impeditivo à aplicação da causa de diminuição. Precedentes.

3. Regime fechado. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Afastamento do caráter hediondo. Precedentes no STF e STJ. Regime aberto que se mostra adequado.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade diante do afastamento do caráter hediondo. Condições subjetivas favoráveis do réu.

5. Pleito de prequestionamento. Desnecessidade de indicação dos fundamentos legais de forma expressa na motivação do acórdão para fins de prequestionamento, desde que haja efetivo debate sobre a matéria. Prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 1501204-56.2020.8.26.0599, 16ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 17.05.2021); e

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleitos de afastamento do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da imposição do retiro pleno - Inviabilidade dos pedidos - Presentes os requisitos do "tráfico privilegiado", deve ser mantida o redutor, bem como os demais benefícios - RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500221-38.2018.8.26.0628, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 17.05.2021). Substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu MOISÉS PICCINE LIRIO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de: (a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em (a.1) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, e (a.2) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma da fundamentação; e (b) 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Dado que o réu respondeu ao processo solto, e remanescendo o mesmo quadro fático-jurídico que animou a concessão da liberdade provisória cumulada com medidas alternativas à custódia cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 CPP). Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do agente em favor da União - consoante fundamentação supra -, o que faço com fulcro no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.343/2006. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração - caso ainda não tenha sido realizada. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Certificado o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado, para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; (d) oficie-se ao IIRGD, para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Cumpridas as demais atribuições cartorárias de praxe, arquivem-se os autos definitivamente, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA